



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE**

composta dai magistrati:

Maria Rosaria Rizzo	Presidente
Paola Agresti	Consigliere
Maria Speranza Ferrara	Consigliere rel.

Sentenza

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8864/2017 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 26.10.2022, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, I c., D.L. n. 137/20201 conv. in l. n. 176/20, e vertente

TRA

Parte_1 (c.f. *C.F._1*), elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Adriana 5, presso l'avv. Osvaldo Pietricola e l'avv. Francesco Pietricola che lo rappresentano e difendono per procura in atti – **APPELLANTE PRINCIPALE -**

E

Controparte_1 (c.f. *C.F._2*), elettivamente domiciliata in Roma, Via Della Balduina 7, presso l'avv. Concetta Trovato che la rappresenta e difende per procura in atti – **APPELLANTE INCIDENTALE -**

Oggetto: appello principale di *Parte_1* e appello incidentale di *Controparte_1*, avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Latina - Sez. Periferica di Terracina, n° 1152/2017, in data 24.05.2017, a definizione del giudizio recante n.r.g. 300020/2010. promosso da *Controparte_1* con domanda riconvenzionale di *Parte_1* – scioglimento di comunione di immobile e domanda di usucapione -

IN FATTO E IN DIRITTO

I fatti di causa sono riportati, come di seguito, nella sentenza impugnata.

<< Con atto di citazione notificato il 12.06.2009 parte attrice conveniva in giudizio il **Pt_1** per lo scioglimento della comunione di un immobile sito in Terracina località Arene via Alcide De Gasperi in N.C.E.U. foglio 205 particella 858 Cat. Al2 divani 5,5 e della annessa corte. Controparte si costituiva avanzando domanda riconvenzionale di avvenuta usucapione per aver posseduto detto immobile per oltre 30 anni uti domino. All'interno di detto giudizio veniva anche richiesto il sequestro giudiziale, concesso con nomina di custode. La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale, interrogatorio formale delle parti, prova per testi e CTU.>>.

La sentenza ha definito la controversia come di seguito.

<< (...) 1) Rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione; 2) Rigetta la domanda di scioglimento della comunione e le relative subordinate; 3) Compensa tra le parti le spese della fase di merito. 4) Condanna **Parte_1** a rimborsare alla parte **Controparte_1** e spese di lite della fase cautelare, che si liquidano in € 4.000,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese forfettarie. 5) Dispone che le spese di CTU arch. **Per_1**, siano poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido così come liquidate, con rimborso alla controparte delle stesse se ed in quanto dalla stessa anticipate in tutto od in parte. 6) Le liquidande spese di custodia e manutenzione (salvo quelle volontariamente accollatesi dal **Pt_1** essendo state necessarie alla salvaguardia della proprietà comune saranno da ripartirsi in parti eguali>>.

Di seguito, le ragioni della decisione.

- Il **Pt_1** sostiene di aver iniziato a possedere l'immobile, in via esclusiva, sin da epoca antecedente alla donazione del 1983, ospitandovi per brevi periodi la comune figlia **Per_1** mera detentrica dell'immobile e che da tale epoca la **CP_1** non avesse più il possesso dell'immobile.
- I coniugi **Parte_2** insieme e *pro indiviso*, hanno acquistato l'immobile nel 1973.
- Intervenuta la separazione personale dei coniugi, nel corso dell'anno 1983, la **CP_1** ha donato, alla comune figlia, la quota indivisa della proprietà del bene (50%).
- Nel corso dell'anno 2008, **Controparte_1** e **CP_2** hanno revocato detto atto di donazione, dunque la **CP_1** è tornata ad essere proprietaria del 50% dell'immobile.

- “Anche prescindendo dall'esame delle prove testimoniali al riguardo”, nell'atto di donazione del 30.03.1983, il **Pt_1** compare quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia, all'epoca minorenni, e in tale veste accetta la donazione in nome e per conto della figlia, dichiarando di prendere possesso della quota donata, circostanza incompatibile con l'allegato possesso esclusivo, che interrompe, ove in corso, il termine ventennale di possesso utile alla usucapione.
- La comune figlia delle parti è nata il 12.05.1969 dunque deve escludersi che eventuali comportamenti tenuti dal padre mentre ancora esercitava la potestà genitoriale possano rilevare come atti di esclusione dal possesso (12.05.1987).
- Il **Pt_1** non ha portato alcuna prova specifica del fatto di aver escluso totalmente dal compossesso dell'immobile la figlia e di aver mutato il titolo del possesso, nel breve periodo di tempo che va dal 12.05.1987 al 12.06.1989, (ventennio antecedente la notifica della domanda giudiziale di divisione, idonea ad interrompere la prescrizione) (Cass. Civ. sez. 11 17321/2015).
- I comportamenti relativi all'incasso di affitti, alla manutenzione ed all'uso diretto da parte del **Pt_1** non sono univoci in quanto essendo comproprietario dell'immobile, il **Pt_1** è legittimato ad incassare i canoni ed è tenuto a mantenere il bene, ben potendo trattarsi di comportamenti tollerati dalla figlia (Cass. Sez. 11 Civ. n. 17462/2009).
- Lo stesso **Pt_1** ha ammesso che la figlia nell'ultimo ventennio ha utilizzato il bene per periodi di studio e svago anche prolungati.
- Quanto alla domanda di divisione proposta dalla **CP_1** l'immobile non è comodamente divisibile; solo la **CP_1** con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c., ha chiesto l'assegnazione del bene (la domanda è stata riproposta a verbale d'udienza del 20.05.2016 con espresso riferimento al valore accertato dal CUI, valore che è di cure 540.000,00, e che, nonostante la stima risalga all'anno 2011, non risulta contestato da nessuna delle parti può ancora ritenersi attuale); dall'esame della CTU (comparazione tra la rilevata consistenza del bene e la piantina depositata in catasto nell'anno 2000) emerge la “successiva parziale chiusura della tettoia con trasformazione della stessa in bagno”; le parti non hanno allegato né documentato la sanatoria dell'abuso edilizio.
- Trattandosi di bene che non proviene da successione ereditaria, non può procedersi alla divisione, all'assegnazione in proprietà o alla vendita

dell'immobile non regolare dal punto di vista urbanistico, in violazione dell'art. 40 L. 47/1985.

- Spese di lite del giudizio di merito, compensate per la reciproca soccombenza,
- Le spese del giudizio cautelare (sequestro) sono a carico del **Pt_1** la cui pretesa di gestire in via esclusiva il bene è risultata infondata.

Con atto di appello, **Parte_1** ha rassegnato le seguenti conclusioni.

<< (...) 1. Accertare e dichiarare l'acquisto a titolo originario (per usucapione) della quota di proprietà del bene immobile conteso, sito nel Comune di Terracina (Latina) alla Via Alcide De Gasperi 5, distinto al N.C.E.U. al foglio 205 particella 858 Cat. A/2 di vani 5,5 e dell'annessa corte (in atti meglio e più dettagliatamente individuata e descritta), della quale risultava e risulta, quale mera intestataria, la Signora [...] **CP_1** odierna appellata, acclarato che la medesima qualificava il Sig. **Parte_1** come "*unico ed esclusivo proprietario*". Con ogni statuizione conseguenziale ed ordine alla competente **Organizzazione_1** di procedere alle necessarie formalità e trascrizione. 2. Disporre che il Signor [...] **Parte_1** cessata la custodia del bene immobile in questione, sia autorizzato a trattenere gli importi tutti sino ad oggi maturati quali frutti del bene stesso. 3. Condannare la Signora **Controparte_1** a rifondere in favore del Signor **Parte_1** le spese di lite, di entrambi i gradi del giudizio (oltre quelle della fase cautelare già liquidate dal Sig. **Parte_1** in favore dell'Avv. Luigi Fioretti per l'importo complessivo di Euro 5.500,00 >>.

Controparte_1 ha resistito all'impugnazione principale; ha proposto appello incidentale e ha rassegnato le seguenti conclusioni.

<< (...): A. rigettare l'appello principale in quanto infondato; B. accogliere l'appello incidentale proposto limitatamente al capo della sentenza impugnato e, in riforma in parte qua della sentenza n. 1152/17 del 24/5/2017 della Prima Sezione Civile del Tribunale di Latina, in persona del Giudice Dott. Antonio Gabrielli: 1) accertare e dichiarare l'ammissibilità della domanda di scioglimento della comunione; 2) per l'effetto, sul presupposto della comunione indivisa pro quota al 50% tra le parti sull'immobile sito in Terracina, località Arene, Via Alcide De Gasperi n. 5, ovvero casa con annesso giardino censito in Catasto Urbano al fg. 205, p.lla 858, procedere, ai sensi dell'art. 784 c.p.c., alla divisione giudiziale di esso, provvedendo sulla scorta della indivisibilità del bene così come riscontrata dal CTU, con sentenza parziale: a) all'assegnazione dell'immobile all'attrice; b) in via subordinata, all'estrazione a sorte

del definitivo proprietario per l'intero; rimettendo la causa sul ruolo per disporre nuova perizia estimativa, onde accertare il reale, effettivo valore del bene ad oggi e così determinare il valore della quota da corrispondere al convivente non assegnatario; C) porre a carico nella misura del 50% le spese relative lo scioglimento della comunione, ed in caso di opposizione nella misura del 100% a carico dell'opponente, con vittoria di lite, onorari e spese >>.

Di seguito, le censure del *Pt_1*

- 1) Vi si sostiene l'illogicità e la contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui rigetta la domanda di usucapione proposta, in via riconvenzionale, dal *Pt_1*. A tal fine il *Pt_1* allega la omessa valutazione delle prove testimoniali espletate dalle quali deve ritenersi provata la adozione di comportamenti del *Pt_1* di esclusione della comproprietaria, idonei ed inequivoci, per un periodo di tempo sufficiente all'usucapione. Il *Pt_1* allega la non configurabilità di una tolleranza basata su rapporti familiari (ormai cessati) e conclude per l'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di usucapione, essendo in tal senso anche il comportamento stragiudiziale della *CP_1* che, con la lettera raccomandata nel 2009e con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha esplicitamente riconosciuto il *Pt_1* atteggiarsi quale "unico ed esclusivo proprietario, perpetuando a concedere in locazione l'immobile senza nulla corrispondere o chiedere alla Signora *Controparte_1*"
- 2) Vi si censura la decisione nella parte in cui ritiene che il *Pt_1* non abbia fornito prova specifica in merito all'esclusione totale dal compossesso dell'immobile della comune figlia *CP_2* e non provato il mutato il titolo del possesso nel breve periodo intercorrente tra il 12.05.1987 e il 12.06.1989. A tal fine richiama le dichiarazioni testimoniali di *Testimone_1* e *Tes_2* [...] (per i quali il *Pt_1* è sempre stato l'unico a possedere *uti dominus* l'immobile, senza soluzione di continuità, dal 1973); le dichiarazioni dei medesimi testi per la parte in cui riferiscono che il *Pt_1* ha provveduto materialmente e finanziariamente a tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria occorse negli anni, sostenendone oneri e spese integralmente; che il periodo ventennale di usucapione decorre dal 13.05.1987 (giorno successivo al compimento del diciottesimo anno della figlia *Persona_3*) fino al

14.05.2007; che la stessa figlia, escussa come teste, ha riferito l'esercizio da parte del padre di un possesso dell'immobile utile alla usucapione.

La CP_1 ha proposto due motivi di impugnazione incidentale.

- 1) Rubricato: *“Nullità della sentenza per errata attribuzione di valore probatorio alle risultanze catastali”*. Vi si censura la decisione nella parte in cui rigetta la domanda di divisione dell'immobile per irregolarità urbanistica dello stesso. A tal fine vi si sostiene che dalla CTU emerge che la costruzione è stata interamente realizzata prima del 1967 (ivi compreso il locale di servizio ricavato dalla parziale chiusura di una tettoia e censurato come abusivo); che all'art. 4 dell'atto notarile di donazione del 50% della comproprietà alla figlia Persona_3 del 1983 si legge: *“il fabbricato descritto in premessa è stato edificato in data anteriore al 1° settembre 1967 e che successivamente a tale data non sono state eseguite opere che richiedessero provvedimenti autorizzativi o concessori, né sono stati irrogati provvedimenti sanzionatori di cui alle suddette leggi”*; che il catasto e le rappresentazioni grafiche contenute nelle planimetrie catastali sono interessati da frequenti errori e può verificarsi che la rappresentazione grafica di una planimetria non corrisponda alla realtà; che, nel concreto, il C.T.U. nulla dice sulla data di costruzione del locale di servizio, limitandosi a riscontrare il mancato riporto del dato fisicamente riscontrato nella planimetria esistente; che tali circostanze possono essere provate a mezzo della testimonianza di Testimone_3 e Testimone_4 [...], la cui escussione richiede in appello in quanto vertente su fatti emersi solo all'esito della emissione della impugnata sentenza.

- 2) Rubricato *“Nullità della sentenza per errata interpretazione delle risultanze istruttorie”*

Vi si censura la sentenza nella parte in cui rigetta la domanda di scioglimento della comunione accertando la presenza dell'abuso e ritenendo la conseguente incommerciabilità del bene. A tal fine, richiamati i principi di diritto in tema di abusi edilizi “minori”, allega che la parziale chiusura della tettoia con trasformazione della stessa in bagno concretizza un abuso “minore” che non comporta la incommerciabilità (e neanche l'indivisibilità) del bene oggetto di causa. Vi si ripropone la domanda di scioglimento della comunione e si richiede, a tal fine, una nuova consulenza limitatamente al valore dell'immobile.

Sull'appello principale.

Le censure riguardano tutte la valutazione della istruttoria che, secondo la prospettazione del Pt_1 ha dato piena prova dei presupposti per l'accoglimento della domanda di usucapione che l'appellante principale ripropone; possono essere valutate congiuntamente e non hanno pregio.

Giova premettere in diritto, che “in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento, anche sul piano probatorio, della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo (Cass. n. 20539 del 30/08/2017) seppure l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà resta soggetto alla regola della "preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile che non" propria del processo civile e non a quella della prova "oltre il ragionevole dubbio" propria del processo penale, stante l'equivalenza dei valori in gioco tra le due parti contendenti nel processo civile e la diversità di quelli in gioco tra accusa e difesa in quello penale” (cfr. Cass. n. 3487 del 06/02/2019).

Più in particolare, “in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24781 del 19/10/2017).

La volontà di possedere *uti dominus* (e non *uti condominus*) non può desumersi da comportamenti che non corrispondano a un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco ed esclusivo del singolo comunista.

“(…) il fatto di aver concesso in locazione a terzi un fabbricato, non può esser ritenuto, isolatamente considerato, un atto di dominio, perché il contratto di locazione può esser stipulato anche da soggetto diverso dal proprietario, purchè abbia la disponibilità di fatto della cosa in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, mentre il possesso deve corrispondere all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, non

ravvisabile nel mero godimento di una cosa ove non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 19196 del 30/09/2005).

L'istruttoria espletata, in parte documentale e in parte testimoniale, non ha fornito la prova puntuale richiesta per l'usucapione ventennale azionata.

Nello specifico.

Il tenore letterale dell'atto di donazione del 1983 dimostra che almeno sino al 12.05.1987, data in cui la figlia delle parti è divenuta maggiorenne, il **Pt_1** ha posseduto la quota di proprietà del bene donata dalla **CP_1** alla comune figlia solo nella sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale.

Il periodo che intercorre tra l'acquisto del bene (1973) e la donazione della quota di proprietà dalla **CP_1** alla comune figlia (1983) non rileva per durata e la valutazione del presupposto in esame, dunque, riguarda il periodo successivo al 12.05.1987.

Con riguardo al lasso di tempo (astrattamente utile a usucapire) che intercorre tra il 12.05.1987 e il 12.06.2009 (data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.

La istruttoria espletata non fornisce prova adeguata del requisito di legge dell'esercizio, sul bene, da parte del **Pt_1** di un possesso esclusivo, pacifico, ininterrotto e ultraventennale.

Nello specifico delle prove orali espletate.

- L'interrogatorio formale delle parti non è sfociato in dichiarazioni confessorie.
- La teste **Persona_3** ha dichiarato di avere avuto, a seguito della donazione del 1983, la materiale disponibilità dell'abitazione e delle chiavi; che i genitori all'epoca erano separati e che la madre era in possesso delle chiavi dell'immobile; di aver vissuto nell'immobile per circa otto mesi tra il 1996 e il 1997; che il padre prima del 2008 non vi ha mai vissuto; di aver preso accordi con il padre circa l'utilizzo dei proventi della locazione stagionale dell'immobile, per la restante parte dell'anno, utilizzato liberamente dalla teste che ne ha dato la disponibilità per brevi periodi anche a terzi (la suocera); di non aver mai corrisposto alcunché al padre per sostenere gli esborsi necessari alla manutenzione dell'immobile in quanto questi tratteneva anche la metà dei ricavi a essa spettanti; di aver disposto personalmente per lavori di potatura degli alberi e la raccolta delle pigne. In buona sostanza, la teste ha dichiarato di aver esercitato facoltà dominicali nelle more del termine dedotto come utile a usucapire (almeno fino al 1997).

- La teste *Testimone_5* ha confermato le circostanze riferite dalla teste *Pt_1*. Non colgono nel segno le censure sulla sua inattendibilità prospettate dall'appellante: l'errata rappresentazione di una abitazione frequentata in poche occasioni e molti anni prima dell'esame testimoniale non è circostanza utile a provare la scarsa credibilità della teste. In ogni caso le circostanze sono riferite anche da altri testi e della prova del possesso utile è onerato il *Pt_1*.
- Il teste *Testimone_6* non riferisce circostanze dirimenti e favorevoli alla tesi del *Pt_1*. Il teste, amico e contabile del *Pt_1* è naturale che abbia frequentato l'immobile allorquando era nella disponibilità del *Pt_1* (e non della *CP_1* o della figlia). Il fatto che il *Pt_1* provvedesse al cambio della serratura del portone al termine di ogni contratto di locazione estiva, rappresenta una cautela del comproprietario rispetto agli estranei inquilini e non rispetto alla comproprietà. Non rileva che il *Pt_1* provvedesse al pagamento dei lavori di manutenzione atteso che la circostanza è compatibile con gli allegati accordi in ordine all'utilizzo dei frutti civili del bene (canoni di locazione), a tacere del fatto che i pagamenti (non possono essere provati per testi e) devono essere documentalmente provati. A tal fine giova rilevare che il teste dichiara di aver riportato i proventi degli affitti in contabilità e di aver avuto conoscenza degli esborsi sostenuti dal *Pt_1* per le medesime ragioni contabili con la conseguenza che la circostanza avrebbe potuto e dovuto essere dimostrata documentalmente (con documentazione diretta a dimostrare inequivocabilmente che i soldi impiegati fossero esclusivamente del *Pt_1* e non derivanti dalle locazioni degli immobili).
- Il teste *Tes_7* ha confermato le dichiarazioni di *Testimone_5* e *Persona_3* e le censure dell'appellante non inficiano l'attendibilità del teste che trova conferma nelle dichiarazioni degli altri testi escussi sul punto.
- Il teste *Testimone_1* ha riferito circostanze relative a un periodo (tra il 1973 e il 1979) che, per quanto sopra in ordine alla interruzione del termine alla data del rogito del 1983, sono irrilevanti. Quanto al periodo 1987-2009. Il teste riferisce solo di aver fornito materiali edili al *Pt_1* per la manutenzione, ma nulla su chi abbia eseguito i lavori e la circostanza, inoltre, non esclude l'utilizzo, diretto o indiretto, del comproprietario ed è compatibile con i contro allegati accordi in ordine all'incasso dei canoni di locazione e alla destinazione di tali proventi per la manutenzione del bene comune.

- Il teste *Testimone_3* conferma le circostanze riferite dai testi *Pt_1* *Tes_5* e *Tes_7* conferma l'utilizzo dell'immobile da parte della figlia comune delle parti nel 1997 e anche nel 1998.
- Il teste *Testimone_8* riferisce di un periodo non rilevante (tra il 1977 e il 1987); per il periodo relativo al 1997 e 1998 è in contrasto con le riportate avverse dichiarazioni; per i pagamenti da parte del *Pt_1* le dichiarazioni incorrono nel limite di cui alla ammissibilità della prova testimoniale e per altro sono generiche e compatibili con gli allegati accordi in ordine alla destinazione dei proventi degli affitti stagionali.
- Il teste *Testimone_9* conferma quanto riferito dalla teste *Pt_1* con riferimento tanto al godimento dell'immobile fino al 1997 -1998, quanto all'impiego dei proventi dal medesimo ricavati, riferendo di conversazioni, cui ha assistito personalmente, tra il *Pt_1* e la figlia in ordine alla riscossione dei canoni di locazione e all'impiego di tali canoni per la manutenzione del bene.
- La teste *Testimone_10* , moglie del *Pt_1* in regime di separazione dei beni, riferisce di aver convissuto in tale abitazione con l'appellante dal 1983 al 1995 ma la circostanza è introdotta dalla teste ed è contraddetta dal pacifico affitto stagionale dell'immobile.
- Il teste *Tes_11* conferma sostanzialmente le dichiarazioni della teste *Persona_3* , con cui è sposato dal 2003, e nulla dichiara sul possesso utile da parte del *Pt_1*
- La teste *Testimone_12* riferisce che il *Pt_1* e la *Tes_10* hanno abitato stabilmente l'immobile per oltre venti anni ma sul punto la generica dichiarazione è disattesa dalla locazione stagionale dell'immobile; quanto alla riferita “ festa a sorpresa” organizzata tra il 1983 e il 1984, è circostanza non dirimente, per quanto sopra in ordine alla interruzione del termine con l'intervento del *Pt_1* nell'atto di donazione del 1983; il riferito pagamento del giardiniere da parte del *Pt_1* incorre nei limiti di ammissibilità della prova di cui sopra e in ogni caso è compatibile con il contro dedotto incasso di canoni e la destinazione degli stessi alla manutenzione dell'immobile, circostanza non contrastata documentalmente con la prova di pagamenti della manutenzione con danaro personale del *Pt_1*

Ciò detto, l'esame complessivo dell'istruttoria espletata impone il rigetto delle censure dell'appellante principale.

L'appello incidentale non ha pregio.

Preliminarmente e sulla prova testimoniale articolata dall'appellante incidentale con la comparsa di costituzione e risposta nel presente grado di giudizio.

La richiesta istruttoria è inammissibile: essa è formulata per la prima volta in questa sede e diretta a provare una circostanza (asseritamente) rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda di divisione, dunque è diretta a provare uno dei presupposti dell'accoglimento della domanda e non, come diversamente allegato dall'appellante incidentale, una circostanza emersa solo con la sentenza impugnata.

Tale considerazione è assorbente.

In ogni caso giova precisare la che prova testimoniale, per come articolata, non è rilevante ai fini del decidere.

La parte, infatti, intende essere ammessa a dimostrare la esistenza, alla data di acquisto dell'immobile (1973) dell'abuso (minore) mentre astrattamente rilevante sarebbe la diversa circostanza della esistenza dell'abuso in epoca antecedente al 01.09.1967.

Per disposto dell'art. 40 l. 47/1985, infatti: *“Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo. Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere*

prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata”

Deve darsi atto della attenuazione, per risalente giurisprudenza, del rigore della portata applicativa di tale disposizione, distinguendosi ormai tra ipotesi di abuso *primario* (relativo a beni immobili edificati o resi abitabili in assenza di concessione e alienati in modo autonomo rispetto all'immobile principale di cui in ipotesi facevano parte) e ipotesi di abuso *secondario* (caratterizzato dalla circostanza che solo una parte di unità immobiliare già esistente abbia subito modifica o mutamento di destinazione d'uso) e ritenendosi applicabile la sanzione della nullità solamente alla prima tipologia di abusi (per non paralizzare oltremodo il traffico giuridico e commerciale del patrimonio immobiliare italiano, spesso risalente nel tempo e affetto da abusi anche modesti).

Gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della detta legge, ove dagli atti non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 (Sez. U, **Sentenza n. 25021 del 07/10/2019**)

Nel concreto.

La domanda di divisione/assegnazione è stata respinta per mancata allegazione e prova dell'avvenuta presentazione di una domanda amministrativa diretta a sanare tale abuso.

Tale punto di accertamento non è stato oggetto di specifica censura in questa sede.

A ciò consegue che non sussistono i presupposti per la invocata attenuazione dei limiti alla circolazione: è necessario, infatti, anche per gli abusi minori e ai fini della circolazione del bene, che per il bene sia stata presentata la domanda condono dell'abuso edilizio minore.

In sintesi.

L'abuso riscontrato è pacificamente annoverabile tra gli abusi cd. *secondari*, involgendo una superficie di neanche tre metri quadrati.

Non è stata allegata né provata dalla parte la presentazione di detta domanda di regolarizzazione (circostanza accertata non è oggetto di censure).

La domanda di divisione dell'immobile (per altro esclusa dal CTU) come anche la domanda di assegnazione dell'immobile non possono essere accolte, non essendo possibile che la sentenza superi i limiti della legge alla attività negoziale delle parti. Né vi è prova del fatto che l'abuso fosse antecedente alla data del 01.09.1967.

L'invocato art. 4 dell'atto di risoluzione di donazione (in data 06.05.2008) non lo dimostra in quanto sul punto l'atto si limita a riportare le dichiarazioni delle parti che, in questa sede, non rilevano ai fini della prova della epoca di realizzazione della difformità.

Infine, le inesattezze della piantina catastale non sono dimostrate.

Spese di lite.

Si compensano per la reciproca soccombenza.

Sanzione processuale.

Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale di *Parte_1* [...] e sull'appello incidentale di *Controparte_1*, avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Latina - Sez. Periferica di Terracina, n° 1152/2017, in data 24.05.2017, a definizione del giudizio recante n.r.g. 300020/2010, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:

- Rigetta l'appello principale.
- Rigetta l'appello incidentale.
- Compensa tra le parti le spese del grado
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.

Roma, 20.12.2022

Il Consigliere Est.

Maria Speranza Ferrara

Il Presidente

Maria Rosaria Rizzo